

1511252-25.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511252-25.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511252-25.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164827/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 18567907 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 36/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2164827 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DA SILVA DE MELO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

WESLEY SOUZA CARNEIRO e HENRIQUE DA SILVA DE MELO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, porque no dia 17 de junho de 2021, por volta das 11 horas e 20 minutos, na Rua Batatais, Parque Residencial Salerno, nesta cidade e Comarca de Sumaré, porque o primeiro trazia consigo, para fins de tráfico, cento e oitenta e oito porções de cocaína, sessenta e oito de cocaína na forma de crack, sete selos contendo a substância 25E-NBOH, constante na lista F2 da Portaria MS 344/98, e cento e cinco porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, enquanto o segundo porque auxiliou o primeiro na prática do

tráfico de drogas.

Notificados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 151/155 e 175/780).

Denúncia recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 185/186).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados (fls. 268/269).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 342/350) pela procedência da pretensão punitiva estatal, uma vez que autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

Alegações finais das Defesas (fls. 353/361 e 362/368) pela improcedência do pedido, alegando que as condutas delitivas não ficaram devidamente comprovadas, inexistindo razões para a condenação dos acusados. Pediram a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/2), pelo boletim de ocorrência (fls.10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), auto de constatação preliminar (fls. 18/22), pelo laudo pericial que resultou positivo para as drogas encontradas em poder de WESLEY (fls. 122/126) e, finalmente, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa

Os policiais civis responsáveis pela diligência disseram que, durante operação nacional integrada denominada "Narco", contra o tráfico de drogas, foram ao local dos fatos e fizeram campana por aproximadamente meia hora, durante a qual notaram os acusados em franca atividade de comércio ilegal de entorpecentes. Henrique funcionava como olheiro enquanto Wesley ia e voltava em posse de uma bolsa nas costas. Ao visualizaram suas presenças, todos fugiram, inclusive outras pessoas que funcionavam como olheiros, tendo sido dispensado, naquela oportunidade, um rádio comunicador. Com Wesley foram encontrados entorpecentes.

A testemunha de defesa, Sirineu Araújo, em Juízo, é proprietário da Padaria denominada "Delícia dos Pães". Relatou que, no dia dos fatos, viu o coacusado Henrique em seu estabelecimento por volta das 11 hrs até 11:30hrs. Sua empresa tem circuito de câmeras e pôde visualizar, a pedido de familiares do coacusado, que ele esteve lá por volta desse horário.

Já a testemunha de defesa Igor Moura de Oliveira, ouvida como informante, confirmou que trabalha com Henrique, seu subordinado. Teceu considerações favoráveis sobre sua conduta social

O acusado Henrique negou a prática do delito. Disse que, minutos antes, esteve numa padaria perto de sua casa fazendo saques num terminal de autoatendimento lá localizado para comprar porções de maconha. Enquanto se dirigia à biqueira, foi abordado por policiais civis.

Já Wesley disse-se usuário de droga e estava lá para adquiri-la quando foi abordado. Acredita que foi confundido com traficantes.

As versões dos acusados, contudo, estão isoladas nos autos sucumbindo a toda a prova produzida, em especial a oral.

Os policiais civis, em depoimento firme, coeso e unívoco, descreveram com detalhes a diligência e apontaram os acusados como as pessoas que atuavam no tráfico de drogas no local, além de outras que não puderam ser identificadas. A certeza com quem apontaram os acusados decorre de campana prévia, por cerca de meia hora, que

lhes possibilitou identificar com a segurança necessária antes de proceder à abordagem.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar os acusados.

É bem verdade que a palavra dos policiais civis na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os agentes foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso". (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

Já o relato das testemunhas de Defesa pouco colabora com o deslinde dos fatos, na medida em que nem mesmo presenciaram a abordagem policial e, por isso, não têm condições de afirmar se a dinâmica policial ocorreu de forma diversa.

A simples juntada de imagens provenientes do circuito de câmeras (fls. 156), cuja localidade exata nem mesmo foi demonstrada pela Defesa, não serve como álibi, vale dizer, prova irrefutável a isentar o acusado de responsabilidade penal. A uma porque, é evidente, o boletim registra o horário estimado da ocorrência; não se trata de registro exato, portanto. Por fim, nada há além dessas imagens a comprovar o local exato onde o acusado estava. Ele, aliás, afirma que ingressou no local para sacar dinheiro; no entanto, nem mesmo prova há de que haja, de fato, um terminal de autoatendimento no local, tampouco evidência de que houve algum saque de dinheiro no momento apontado pela Defesa, prova fácil de ser obtida seja por extrato bancário ou mediante requerimento de ofício do Juízo à instituição financeira. A prova, portanto, é frágil e não isenta o acusado de responsabilidade.

Inexistem, ademais, excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

No mais, a quantidade de droga e a forma de acondicionamento e as demais circunstâncias permitem a segura conclusão de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico. Não há cogitar, portanto, de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Configurado, assim, o delito de tráfico (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), cujo

preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

WESLEY SOUZA CARNEIRO

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do art. 59, do CP (art. 42, da Lei n. 11.343/06), observo que não são inteiramente favoráveis.

Isso devido à variedade e natureza das drogas, das quais se destaca o crack e cocaína, substâncias com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante; possuem natureza deletéria diferenciada de outras substâncias entorpecentes, aptas a atingir um número significativo de usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao bem jurídico da saúde pública, razão pela qual deve o Estado manter uma postura mais rígida diante deste tipo de crime e, em especial, deste tipo de entorpecente.

A culpabilidade é normal à espécie, a conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos, os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O acusado não ostenta maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda etapa: não há agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Não há causa de aumento. Observo que, a despeito da primariedade do acusado, este não faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, quase trezentas porções, incluída aí droga sintética conhecida por LSD, suficiente, portanto, à manutenção do vício de uma miríade de usuários, indica que seu perfil não se subsume àquele que o legislador pretendeu atingir com a elaboração do § 4º. Soma-se a isso que sua prisão em flagrante foi precedida de campana que pôde apurar o comportamento do acusado, não condizente com o do traficante ocasional. Praticava o tráfico em concurso de pessoas, tudo a indicar habitualidade incompatível com o privilégio, conforme, aliás, precedente do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "(...)

7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...]" (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Carmen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Desta feita, deixo de aplicá-lo. Por consequência, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

HENRIQUE DA SILVA DE MELO

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do art. 59, do CP (art. 42, da Lei n. 11.343/06), observo que não são inteiramente favoráveis.

Isso devido à variedade e natureza das drogas, das quais se destaca o crack e cocaína, substâncias com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante; possuem natureza deletéria diferenciada de outras substâncias entorpecentes, aptas a atingir um número significativo de usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao bem jurídico da saúde pública, razão pela qual deve o Estado manter uma postura mais rígida diante deste tipo de crime e, em especial, deste tipo de entorpecente.

A culpabilidade é normal à espécie, a conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos, os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O acusado não ostenta maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda etapa: não há agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Não há causa de aumento. Observo que, a despeito da primariedade do acusado, este não faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, quase trezentas porções, incluída aí droga sintética conhecida por LSD, suficiente, portanto, à manutenção do vício de uma miríade de usuários, indica que seu perfil não se subsume àquele que o legislador pretendeu atingir com a elaboração do § 4º.. Soma-se a isso que sua prisão em flagrante foi precedida de campana que pôde apurar o comportamento do acusado, não condizente com o do traficante ocasional, já que portava equipamentos que revelam requinte como rádio comunicador. Praticava o tráfico em concurso de pessoas, tudo a indicar habitualidade incompatível com o privilégio, conforme, aliás, precedente do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "(...)"

7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...]" (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Carmen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Desta feita, deixo de aplicá-lo. Por consequência, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena aplicada, reputo adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §§ 2º, "a", e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista a quantidade de pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar:

A) HENRIQUE DA SILVA DE MELO, já qualificado nos autos, à pena de reclusão pelo prazo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado, bem como a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

B) WESLEY SOUZA CARNEIRO já qualificado nos autos, à pena de reclusão pelo prazo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado, bem como a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Subsistem os requisitos, pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, pelo que denego aos acusados a prerrogativa de recorrer em liberdade, devendo ser recomendados desde logo no estabelecimento prisional onde se encontra.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), ainda não preenchido, mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 112, da LEP. Além de não preenchido o requisito objetivo, ante a quantidade de pena imposta, não há ainda notícia de eventual bom comportamento carcerário dos acusados, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele quem possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se, se o caso, a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do

Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 9 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA